

0010533-96.2022.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Galizia Noriega

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 28ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... estar caminhando por outro motivo que não o tráfico, mas como se viu, saiu do caminho dos usuários de drogas justamente porque tinha drogas em seu poder, praticando ato ilícito, registrando-se que o tráfico é crime permanente.

As drogas foram apreendidas e periciadas. O réu confessou que estava no tráfico. É primário e a quantidade de droga permite o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

28ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0010533-96.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0010533-96.2022.8.26.0050

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Tipo Completo da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>

Réu:

ERIC SILVESTRE DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Galizia Noriega

Vistos.

ERIC SILVESTRE DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque trazia consigo, para a entrega a consumo de terceiros, (iii) 1,1g (um grama e um decigrama) de Cannabis sativa L, planta da qual se origina o psicotrópico Tetraidrocanabinol - THC e (ii) 14,7g (quatorze gramas e sete decigramas) de cocaína, substâncias capazes de causar dependência, relacionadas na Portaria SVS/MS 344/98 como de uso proibido, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Boletim de ocorrência (fls. 07/08). Auto de exibição e apreensão (fls. 32/33). Laudo de constatação (fls. 11/14). Laudo de exame químico toxicológico (fls. 189/191).

Folha de antecedentes e certidões - fls. 87/91 e 98/114.

O réu foi notificado (fls. 184).

Apresentada defesa preliminar em favor do réu (fls. 202).

Recebida a denúncia (fls. 204). O réu foi citado (fls. 321).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns e foi interrogado o

acusado.

Nada foi requerido na fase do art. 402 do CPP.

Em suas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, com a aplicação do redutor e substituição por restritiva de direitos.

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu, por insuficiência de provas. aduzindo nulidade da prisão feita pela guarda civil. Subsidiariamente, pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, a aplicação do redutor em seu grau máximo, a substituição por pena restritiva de direitos, a fixação do regime aberto e o direito ao recurso em liberdade.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do crime de tráfico restou bem comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de exame químico toxicológico positivo.

A autoria, de igual modo, restou devidamente demonstrada, na medida em que os guardas civis ouvidos em juízo relataram, de forma harmônica, como se deu a abordagem do réu e o encontro das drogas.

Registre-se que a abordagem efetuada pelos guardas civis não é ilegal, pois a própria lei faculta a qualquer do povo a prisão em flagrante, tratando-se, portanto, de ação legítima a dos guardas civis, mormente em se tratando de atitude suspeita do acusado, na cracolândia, desgarrando-se do fluxo, situação típica de quem é traficante e não mero usuário. Não seria razoável impedir a atuação da guarda civil municipal que é justamente a que está presente em maior número na cracolândia e conhece exatamente como é feita a movimentação do fluxo, sendo apta a verificar situações suspeitas e a fundada suspeita autoriza a abordagem.

Neste sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDAS MUNICIPAIS. ILEGALIDADE. DESVIO DE FUNÇÃO. PROVAS ILÍCITAS. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE AUTORIZADA. BUSCA PESSOAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AUSÊNCIA. DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADAS. (...) III - A respeito da busca pessoal realizada, sabe-se que o artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal preceitua que será realizada "busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior". Por sua vez, o artigo 244 do aludido diploma legal prescreve que "a busca pessoal independe de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". Da leitura dos referidos dispositivos, depreende-se que a revista pessoal independe de mandado quando se está diante de fundada suspeita de que o indivíduo traz consigo objetos ilícitos. IV - In casu, ao contrário do que sustentado na presente insurgência, verificasse que configuraram-se as fundadas razões exigidas pela lei processual, uma vez que o ora agravante, que trafegava por via pública já conhecida pelos agentes como ponto utilizado para a realização do comércio espúrio com uma sacola em suas mãos, ao notar a presença de equipe policial que realizava patrulhamento de rotina, apresentou acentuado nervosismo, o que causou estranheza nos milicianos, que decidiram, somente então, realizar a abordagem. Por conseguinte, havendo, de fato, fundada suspeita de que o paciente estava na posse de objetos ilícitos, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada (...) (STJ, AgRg no HC 684062/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe de 03/11/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA. PRISÃO REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. OCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. USO DE DROGA NO MOMENTO DA ABORDAGEM. BUSCA NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO FRANQUEADA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REITERAÇÃO DE OUTRO HC. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Considera-se lícita a revista pessoal executada por guardas municipais, com a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. § 2º do art. 240 do CPP, bem como a prova derivada da busca pessoal. 2. Configurada a situação de flagrância, com a demonstração de fundada suspeita, não se verifica ilegalidade na realização de abordagem pessoal por guardas municipais que estavam em patrulhamento com cães farejadores, encontrando drogas com o paciente e nas proximidades do local do flagrante, pois o acusado informou que estava usando drogas no momento em que foi abordado. 3. A questão referente à aplicação da minorante, a matéria já foi analisada no HC 563.700/SP, tratando-se de mera reiteração de pedido. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 597.923/SP- Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça - Relatr Ministro Nefi Cordeiro - J. em 20.10.2020- DJe 26.10.2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO RATIFICADA EM GRAU DE APELAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA PELA GUARDA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. ART. 301 DO CPP. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Apesar das atribuições previstas no art. 144, § 8º, da Constituição Federal, se qualquer pessoa do povo pode prender quem quer que esteja em situação de flagrância, não se pode proibir o guarda municipal de efetuar tal prisão (HC 286.546/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 15/10/2015). 2. Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que inexistente irregularidade na prisão em flagrante promovida por guardas municipais, estando suas condutas amparadas pelo art. 301 do Código de Processo Penal, segundo o qual qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, como ocorreu na hipótese dos autos. 3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC 592.722/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. NULIDADE DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. PROVA ILÍCITA. INEXISTÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PARECER ACOLHIDO. (...) 2. Na hipótese dos autos, não há falar em nulidade da sentença e do acórdão sob a alegação de irregularidade na prisão em flagrante, visto que os integrantes da Guarda Municipal flagraram o paciente, em via pública, na posse de entorpecentes destinados à mercancia, estando suas condutas amparadas pelo art. 301 do Código de Processo Penal, segundo o qual qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. 3. Apesar das atribuições previstas no art. 144, § 8º, da Constituição Federal, se qualquer pessoa do povo pode prender quem quer que esteja em situação de flagrância, não se pode proibir o guarda municipal de efetuar tal prisão. 4. Em razão do caráter permanente do tráfico de drogas, cuja consumação se prolonga no tempo, a revista pessoal ou domiciliar que ocasionou a prisão em flagrante, não representa prova ilícita (Precedente). (STJ-HC 286.546/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 15/10/2015).

TRÁFICO - Nulidade da prisão efetuada por Guardas Municipais - Ausência de legitimidade dos Guardas Municipais para realização de busca pessoal - Ilicitude das provas colhidas - Prisão em flagrante que pode ser realizada por qualquer

pessoa do povo - Art. 301 do CPP - Nulidade não reconhecida - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito - Depoimentos de guardas municipais - Inexistência de contradição ou confronto com as demais provas - Análise que se faz em cada caso concreto - Ausência de dúvida que justifica o decreto condenatório - Condenação mantida - Pena-base reduzida ao mínimo legal - Acusado reincidente - Impossibilidade de aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas - Regime inicial fechado justificado pela reincidência - Recurso parcialmente provido (voto nº 41452). (TJSP; Apelação Criminal 1500200-65.2019.8.26.0551; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araras - Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/01/2020; Data de Registro: 29/01/2020).

"Ademais, em que pese controvertida a extensão da das atribuições das guardas civis metropolitanas, havendo, inclusive, recurso extraordinário sobre o tema, cuja repercussão geral foi reconhecida (RE 608.588/SP, Rel. Min. Luiz Fux), extrai-se do art. 301 do CPP que qualquer do povo poderá prender quem quer se encontre nas hipóteses de flagrância do art. 302, e que as autoridades policiais tem o dever de realizar o flagrante. Assim, embora a guarda municipal não se enquadre no conceito de "autoridade policial", inequivocamente tem aptidão para realizar o flagrante facultativo" (Habeas Corpus Criminal nº 2039080-05.2021.8.26.0000 - 7ª Câmara de Direito Criminal - Relator Des. Reinaldo Cintra - J: 25.3.2021).

Afastada a alegação defensiva de nulidade, passa-se à análise do mérito. Gilmar GCM, reconheceu o réu Eric em juízo e não o conhecia antes dos fatos. Após o retorno do fluxo, o pessoal que ficava na praça do cachimbo tinha que sair da praça para a limpeza. Eric pegou outro caminho, diferente do caminho que o pessoal fazia para o retorno. Acharam estranho e chamou a atenção. Abordaram e na busca pessoal encontraram nas partes íntimas do Eric porções análogas a cocaína e levaram ele ao DP. No dia ele informou que ia ganhar algo em troca, mas não falou detalhes. Abordaram outra pessoa na mesma data, por tráfico de drogas. Se não se engana eram 19 papелotes de cocaína. Ele não tinha ligação com o outro cidadão que foi abordado por tráfico também. Pelo que se recorda não havia outra droga, balança de precisão, faca. O que foi encontrado com ele foi apresentado para o delegado de plantão. O réu mudou o caminho, havia um padrão ali, tanto os usuários quanto a guarda civil tinham um padrão de alinhamento para entrada e retorno dos usuários. Ele se desgarrou do fluxo. Ele estava sozinho quando suspeitaram dele. Foi a mudança de fluxo o que levantou a suspeita. Somente Eric seguiu o caminho inverso ao dos usuários. Eles tem ciência da entrada e retorno para a antiga praça do cachimbo.

Jilcimar, GCM, reconheceu o réu em juízo e não o conhecia antes dos fatos. Relatou que na data e horário dos fatos acontecia a limpeza da praça do cachimbo, na famosa cracolândia. Após a limpeza dava-se o sinal e o fluxo todo retornava à praça e existe um padrão de descida, todo mundo desce pela Helvetia. O réu saiu do fluxo e tomou outro sentido, o que chamou a atenção e ele foi abordado. Em busca, na parte íntima encontraram porções análogas a cocaína. Ele disse que receberia algo em troca para entrar no fluxo com a droga. Não tinham mais ninguém com ele. Fizeram a prisão de outra pessoa, no mesmo local, mas não estava com ele. O réu foi abordado primeiro. O outro tentou passar com faca, pedras de crack nas pernas dele. O fato de se desgarrar do fluxo gera suspeita porque se forma uma linha de policiais, com viatura, afunilando, para que eles não levem lixo para dentro. A maioria deles quando porta droga ou dinheiro, arma, faca, eles tomam outro rumo. Não teria motivo para ele desviar, porque não é feita revista. Se ele sai e porque está com medo de alguma coisa.

Interrogado o réu confessou a prática do delito. Nunca teve envolvimento anteriores. Não sabe quanto ia ganhar para passar com a droga pela cracolândia. Mora com sua mãe. Estudou até o 2º colegial. Parou de estudar porque estava trabalhando, ajudante de pedreiro. Trabalha atualmente como ajudante de pedreiro. Ganha 180,00 por dia. Trabalha por conta. O conjunto probatório é suficiente para a procedência da ação penal.

O réu confessou a prática delitativa e a confissão encontra pleno respaldo na prova oral colhida.

Os guardas civis reconheceram o réu e confirmaram que houve encontro das drogas em poder do réu e ele, por sua vez, confessou que estava com a droga e não soube dizer quanto ganharia para passar com a droga pela cracolândia.

Os guardas relataram de maneira harmônica como foi a abordagem do acusado e o encontro em poder dele das drogas, nas partes íntimas, o que foi confirmado pelo réu.

Ao contrário do alegado pela Defesa, os guardas civis relataram que o réu destoou do fluxo, indo para outro local e desrespeitando a recomendação que já é de ciência de todos, o que ensejou a abordagem e explicaram que cada um dos dois indivíduos presos no dia dos fatos foi abordado em momento diferente. O argumento de que eles não têm uma memória suficientemente clara não afasta o fato de que reconheceram o réu em juízo, confirmaram a abordagem e o encontro das drogas em suas partes íntimas, repetindo-se que o réu confessou a prática do tráfico e inquirido por esta magistrada, disse que não queria esclarecer os motivos para a prática do delito. Houve versões harmônicas sobre a fundada suspeita e a abordagem e ainda que tenha a Defesa apontado contradições entre os depoimentos na fase extrajudicial e em juízo, tais argumentos não macularam a prova produzida em juízo que, repita-se, confirmou a abordagem por fundada suspeita, o encontro da droga e a confissão informal do réu, tendo sido corroborada pela confissão judicial.

O réu poderia estar caminhando por outro motivo que não o tráfico, mas como se viu, saiu do caminho dos usuários de drogas justamente porque tinha drogas em seu poder, praticando ato ilícito, registrando-se que o tráfico é crime permanente.

As drogas foram apreendidas e periciadas. O réu confessou que estava no tráfico. É primário e a quantidade de droga permite o reconhecimento do tráfico privilegiado. Assim, considerado o conjunto probatório amalhado, a absolvição do réu é meta impossível de se alcançar, porém, faz jus à aplicação do artigo 33, § 4º da Lei de Drogas.

Caracterizado o delito de tráfico passo à fixação da pena com fulcro nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Respeitado o sistema trifásico fixo a pena-base no mínimo legal, por ser o réu primário. Pena-base, portanto, em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase não há agravantes. Reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa, porém, sem reflexo na pena, pois no mínimo legal.

Na terceira fase não há causas de aumento. Reconhecido o tráfico privilegiado, a pena sofre redução de 2/3, resultando em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão. A pena pecuniária é fixada, utilizados os mesmos critérios da pena privativa de liberdade, em 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso.

O réu faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, de forma a ser deliberada em sede de execução, pelo mesmo período da pena privativa de liberdade ora imposta; e no pagamento de prestação pecuniária no valor de um salário mínimo em benefício de instituição de saúde a ser designada pelo juízo das execuções, para aquisição de insumos hospitalares em razão da pandemia de Covid.

Fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, para a hipótese de revogação da substituição.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu ERIC SILVESTRE DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso, no piso, por incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, de forma a ser deliberada em sede de execução, pelo mesmo período da pena privativa de liberdade ora imposta; e no pagamento de prestação pecuniária no valor de um salário mínimo em benefício de instituição de saúde a ser designada pelo juízo das execuções, para aquisição de insumos hospitalares em razão da pandemia de Covid.

Faculto o apelo em liberdade.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Independentemente do trânsito em julgado, já tendo sido apresentado o exame químico toxicológico definitivo, autorizo a incineração da droga, nos termos do art. 32 da Lei nº 11.343/06. Oficie-se.

Deixo de condenar o réu ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, em razão da atuação da Defensoria Pública do Estado.

P.R.I.C.

São Paulo, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA